InDret
REVISTA PER
L'ANÀLISI DEL DRET

WWW. INDRET.COM

Adquisicions oneroses i titularitats dubtoses en el règim de separació

Els articles 232-3 i 4 del Codi Civil de Catalunya

Lídia Arnau Raventós

Facultat de Dret
Universitat de Barcelona

BARCELONA, OCTUBRE 2011

Abstract[*]

Es proposa un comentari dels arts 232-3 i 4 del Codi civil de Catalunya que, en seu de règim econòmic de separació, pretenen facilitar la determinació del patrimoni propi de cada cònjuge. El primer ho fa a propòsit dels béns adquirits onerosament durant el matrimoni per un d´ells. La finalitat de la disposició seria, en tot cas, preservar el sistema general d´adquisició de titularitats reals en aquells casos en què la contraprestació satisfeta prové del patrimoni del cònjuge no-adquirent. Defugint de tota idea de subrogació real, es dóna resposta al supòsit presumint que s´ha atorgat una donació entre cònjuges. La segona d´aquelles disposicions encara la qüestió de les titularitats dubtoses.

We propose a comment of articles 232-3 and 4 of the Catalan Civil Code of Catalonia, which seeks to facilitate the determination of the equity of each spouse married under a separate property regime. Article 232-3 refers to assets acquired during the marriage in which one of the spouses holds the title to ownership yet the price is actually paid by the other spouse. The provision deems this payment a gift to the title-holder. Article 232-4 deals with the issue of uncertain entitlements.

Title: Acquisitions for consideration and dubious titles in a matrimonial separation of property system: articles 232-3 and 232-4 of the Catalan Civil Code.

Paraules clau: règim de separació, titularitat formal, presumpció legal
Keywords: Separation of Property, Legal Title, Legal Presumption

[*]Aquest treball forma part del Projecte DER 2011/26892 i de la investigació desenvolupada dins del Grup d'Investigació consolidat 2009 SGR 221, del que n'és investigador principal el Prof. Ferran Badosa Coll.

Sumari

1. Introducció
2. Les adquisicions oneroses
2.1. La pertinença del bé a l'adquirent a títol onerós
2.2. La presumpció de donació de la contraprestació satisfeta
2.2.1. El fet base: l'adquisició i la procedència de la contraprestació
2.2.2. El fet presumpte
a. L'antecedent: l'art. 21, 2n par. CDCC
b. L'àmbit d'aplicació de l'art. 232-3.1 CCCat: les relacions entre cònjuges
c. El règim de la donació presumpta. La prova en contrari
2.2.3. De la presumpció de donació entre cònjuges a propòsit de l'adquisició onerosa d'un bé…a la presumpció de gratuïtat en els negocis entre cònjuges?
2.3. La presumpció de titularitat compartida i a parts iguals indivises
3. Titularitats dubtoses
4. Taula de jurisprudència citada
5. Bibliografia

1. Introducció

El CCCat dedica els arts. 232-3 i 4, respectivament, a les adquisicions oneroses i a les titularitats dubtoses en el règim econòmic matrimonial de separació de béns. En ambdós casos, es tracta de normes en matèria de titularitat real. Així, en ambdós casos, es declara a qui pertanyen determinats béns, ja sigui els adquirits onerosament, ja sigui aquells dels que se'n dubta la titularitat. Des d'aquesta perspectiva, aquells articles estarien al servei de l'art. 232-2 CCCat, relatiu a la composició del patrimoni propi de cadascun dels cònjuges; en concret, ajuden a concretar-ne l'abast en cas de béns adquirits després de la celebració del matrimoni.

2. Les adquisicions oneroses

En aquell context de determinació del patrimoni propi de cadascun dels cònjuges, l'art. 232-3 CCCat tracta dels béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni. I això als efectes: primer, de declarar la seva pertinença al cònjuge que "consti" com a titular; segon, de confirmar l'aplicació d'aquesta mateixa regla encara que la contraprestació satisfeta procedeixi del patrimoni del cònjuge no adquirent; tercer, d'excepcionar-la en cas d'adquisició onerosa de "béns mobles de valor ordinari destinats a l'ús familiar". En aquest darrer supòsit, es presumeix la pertinença del bé a ambdós cònjuges i en proindivís.

2.1. La pertinença del bé a l'adquirent a títol onerós

L'art. 232-3.1 CCCat declara, en primer terme, la pertinença del bé al cònjuge que "consti" com a titular. La regla demana que concorrin quatre requisits relatius, respectivament, a la temporalitat de l'adquisició, a la seva naturalesa, a la del bé adquirit i a la constància de la titularitat. Així, més enllà d'haver-se verificat durant el matrimoni, l'adquisició ha de ser onerosa i recaure sobre bé que no sigui moble de valor ordinari destinat a l'ús familiar (art. 232-3.2 CCCat *a contrari*). A propòsit d'aquella constància (altrament: que d'alguna manera aparegui "a nom" d'un dels cònjuges), s'hauria d'entendre suficient la "mera prova de la titularitat formal" (art. 232-3.2 *in fine* CCCat *a contrari*). Això últim: d'una banda, no prejutja la possibilitat d'acreditar que qui consta com titular realment no ho és d'acord amb el sistema general d'adquisició de titularitats reals; per una altra, sí que permet descartar que, a fi de declarar la pertinença del bé al titular formal, calgui acreditar el caràcter autofinançat de l'adquisició.

> L'art. 232-3.1 CCCat no està pensant en el cas de manca de correspondència entre la titularitat formal (la titularitat que només consta) i la real, ni molt menys pretén fer prevaler la primera sobre la segona. Es diria que pressuposa aquella coincidència. Des d'aquesta perspectiva, el precepte no té valor normatiu; altrament: al proclamar la pertinença del bé a favor de qui consta com titular no s'altera el sistema general d'adquisició de titularitats reals. I d'aquí que la dita declaració de pertinença pugui predicar-se, de la mateixa manera i amb idèntica repercussió, en cas d'adquisicions no oneroses o d'adquisicions al marge de tot context matrimonial. La finalitat de l'art. 232-3.1 CCCat en aquest particular és una altra: descartar que aquell sistema general es vegi alterat o compromès en casos d'adquisició finançada per altri. D'aquí que la norma contempli només adquisicions oneroses, limitant així el seu àmbit d'aplicació a aquelles que suggereixen o permeten plantejar la qüestió. Sobre això, vegeu la SAP Barcelona, Secc. 17a,

28.5.2007 (JUR 2007\295084; *MP: Amèlia Mateo Marco*) i la SAP Barcelona, Secc. 14a, 4.11.2003 (JUR 2004\4484; *MP: Mª Eugenia Alegret Burgès*). En ambdues, constant el bé a nom de l'esposa, el marit pretén que es reconegui la seva participació en aquella titularitat. En el primer cas, s'al·lega l'existència d'un negoci fiduciari i, en el segon, simulació subjectiva. El Tribunal no va considerar provats ni l'un ni l altre. En el cas resolt per la STSJ Catalunya, Secc. 1a, 7.6.2010 (RJ 2010\3750; *MP: José Francisco Valls Gombau*), el marit defensava haver-se atorgat un "negoci fiduciari afectat per simulació relativa". El Tribunal, després de posar de manifest la contradicció inherent a l'argument (FJ 2n, apartat 3r, 2n parell.: "…por contraposición al negocio simulado, que no tiene causa y es radicalmente nulo, el fiduciario lleva insita la 'causa fiduciae'…"), acaba també entenent que ni aquella causa s'ha provat, ni esquivat la presumpció de donació del llavors vigent art. 39 Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família (DOGC núm. 2687, de 23.7.1998; en endavant, CF).

La no-necessitat d'acreditar la satisfacció del preu o contraprestació amb recursos procedents del patrimoni de l'adquirent es justificaria: primer, pel fet de no exigir-se legalment aquesta prova; segon, per la mateixa amplitud de la terminologia legal que permet aplicar la norma fins i tot en aquells casos en què, tot i haver-se produït ja l'efecte adquisitiu, el pagament o compliment de la contraprestació encara està pendent. I ho acabaria confirmant, sobretot, la presumpció de donació que regeix en el concret supòsit de finançament aliè previst al mateix art. 232-3.1 *in fine* CCCat.

L'art. 232-3.1 CCCat no coincideix, en aquest particular, amb els seus precedents (art. 39 CF, art. 49 *in fine* Decret Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Compilació del Dret civil de Catalunya [DOGC núm. 456, de 27.7.1984; en endavant, CDCC] i art. 21, 2n par. CDCC [aquest darrer segons la redacció donada per la Llei 8/1993, de Modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges; DOGC núm. 1807, de 11.10.1993]). Més que de la titularitat del bé (de la que, simplement, no se'n parlava), s'ocupaven de la procedència de la contraprestació, que ubicaven presumptament en el patrimoni de l'adquirent (art. 39 CF: "En les adquisicions fetes a títol onerós per un dels cònjuges durant el matrimoni, si consta la titularitat dels béns, la contraprestació s'entén pagada amb diners de l'adquirent"). La titularitat del cònjuge adquirent no es qüestionava, però no perquè la presumpció que sí que establia la norma implícitament ja resolgués la qüestió (com si es pensés que, evidentment, els béns només poden ser dels qui els han adquirit sufragant, a més a més, el seu cost amb béns o diners propis), sinó perquè s'havia d'analitzar atenent al sistema general d'adquisició de titularitats reals. Ho confirmava el fet que la contraprova (acreditativa d'una altra procedència) només podia servir per deixar provat que l'adquirent o titular no va pagar o no ho va fer amb diners propis (així, perquè ho va fer un tercer), però no per a arrabassar-li, per aquest únic fet, aquella titularitat (vegeu, negant que l'art. 21 CDCC admetés prova en contrari, NAVAS NAVARRO [1994, p. 1]). Pel contrari, de la titularitat del cònjuge adquirent sí que en parla l'art. 232-3.1 CCCat. I ho fa: primer, sense incorporar ni modificar cap regla patrimonial; segon, sense afegir tampoc cap presumpció legal relativa a la procedència de la contraprestació i, més concretament, sense afegir-ne cap que la situï en el patrimoni de l'adquirent (contràriament, deduïnt-la igualment de l'art. 232-3.1 CCCat, vegeu SOLÉ RESINA [2010, p. 186] i BAYO DELGADO [2011, p. 688]; quant a la possibilitat de presumir judicialment aquella procedència, vegeu art. 386 LEC). Sent això així, en el context de la presumpció de donació de l'art. 232-3.1 *in fine* CCCat, acreditar que l'origen del preu satisfet se situa en el patrimoni del cònjuge no-adquirent no s'exigeix a fi de desvirtuar la presumpció de que aquell origen és el patrimoni de l'adquirent. Al contrari, atès que són possibles procedències distintes (així, aquell patrimoni, el del cònjuge no adquirent, el d'un tercer…), la norma fa referència només a una de les circumstàncies que integren el fet base i que, d'acord amb les regles generals en matèria de càrrega de la prova, correspon provar a qui al·lega la presumpció (art. 385.1, 2n par. LEC).

2.2. La presumpció de donació de la contraprestació satisfeta

La procedència aliena de la contraprestació satisfeta no altera la regla general, la que sigui, relativa a qui adquireix (Preàmbul III, par. 5è, Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals [DOGC núm. 4640, de 24.5.2006]). Això s'adiu del tot amb un sistema general d'adquisició dels drets reals en virtut de títol contractual seguit de tradició que prescindeix de l'onerositat o gratuïtat del primer; de si, tractant-se de contracte onerós, s'ha satisfet o no el preu i, en el primer cas, de la seva procedència.

> De la mateixa manera que a propòsit de l'adquisició dels drets reals en el CCCat, el Capítol I del Títol III del Llibre V té un abast limitat malgrat la generalitat de la seva rúbrica (BADOSA COLL, 2009, p. 37), l'onerositat va més enllà del negoci de transmissió (analitzant-la només a propòsit de negocis d'aquest tipus: BADOSA COLL, 2009, p. 109). La raó seria que l'onerositat o gratuïtat també poden predicar-se d'adquisicions que no demanen ni es justifiquen en un negoci previ d'aquella naturalesa. L'argument el proporcionen aquells drets reals d'adquisició preferent l'efecte adquisitiu dels quals se supedita a la satisfacció o pagament d'un preu o contraprestació; es tractaria de requisits de l'eficàcia adquisitiva del dret d'adquisició (o, millor, del seu exercici) i no circumstàncies de la transmissió, que estrictament no n'hi ha (arts. 568-1, 568-6 b i 568-12.1 CCCat; art. 328.1 CDCC; predicant l'onerositat de l'adquisició vegeu, també, arts. 231-12 i 15 CCCat).

Sent això així, per al cas de procedir aquell preu o contraprestació del patrimoni del cònjuge no adquirent, l'art. 232-3.1 CCCat presumeix la seva donació a qui sí que va adquirir. D'aquesta manera, doncs, el supòsit es resolt sense alterar ni el sistema ni el resultat adquisitius. Pel contrari, aquella resolució passa per analitzar la naturalesa del negoci presumptament atorgat entre els cònjuges, l'objecte dels quals és el preu satisfet a tercer. Es tracta, aquesta sí, d'una norma de dret matrimonial.

2.2.1. El fet base: l'adquisició i la procedència de la contraprestació

Acreditada l'adquisició onerosa d'un dels cònjuges, haurà de provar-se també "que la contraprestació es va pagar amb béns o diners de l'altre". No podrà aportar-se prova d'aquella primera circumstància, però sí de la segona, en aquells supòsits en què s'ha satisfet tot o part del preu però l'adquisició encara no s'ha produït (així, perquè tractant-se d'un contracte amb finalitat transmissiva, encara no s'ha fet lliurament de la cosa o perquè s'ha pactat una reserva de domini a favor del venedor).

A propòsit del pagament o compliment amb béns o diners del cònjuge no-adquirent, la literalitat de l'art. 232-3.1 CCCat suggereix preguntar-se per qui i què es va pagar. En relació al *solvens*, el "es va pagar" permet incloure tant el pagament satisfet pel propi cònjuge adquirent (supòsit en el que, probablement, està pensant la norma), com al realitzat pel no-adquirent.

> Es fa ús també de la forma impersonal a l'art. 231-12 CCCat; en canvi, l'art. 78.1 Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal (BOE núm. 164, de 10.7.2003; en endavant, LC) exigeix que el pagament s'hagi satisfet pel cònjuge del deutor concursat.

En aquest segon cas, el joc de la presumpció permetria concebre el supòsit com de pagament per tercer o de deute aliè amb ànim extintiu de l'obligació, descartant-se així l'opció de l'art. 1210 CC, i amb *animus donandi* respecte del seu cònjuge, tancant-se també la de repetició de l'art. 1158, 2n par. CC (art. 1894, par. 1r, *in fine* CC i art. 237-11.1 *in fine* CCCat). I això seria així independentment que, tractant-se d'una adquisició onerosa realitzada a fi de satisfer necessitats familiars, el cònjuge no-adquirent assumís legalment, i enfront del creditor, una responsabilitat solidària (art. 231-8 CCCat). Això últim simplement implicarà la possibilitat de reclamar-li el deute malgrat no haver participat en el contracte ni, en conseqüència, haver adquirit la condició de deutor. D'aquí que, en cas de satisfer-se, el pagament igualment serà de deute aliè.

Del que s'ha dit es desprèn, doncs, que l'art. 232-3.1 CCCat incorpora una presumpció *d'animus donandi* en el cònjuge no-adquirent que, sent responsable malgrat no ser deutor, finalment satisfà el deute (a propòsit de la configuració del supòsit previst a l'art. 8 CF com un de responsabilitat sense deute vegeu, GOMEZ POMAR [2000, p. 122] i MIRAMBELL ABANCÓ [2003, p. 454]); d'altra banda, confirmant que la qualificació com a despesa familiar d'una determinada adquisició, no implica que el bé adquirit sigui comú, vegeu, a propòsit de l'adquisició de la vivenda familiar, SAP Barcelona, Secc. 13a, 29.7.2004 [JUR 2004\288508; *MP: Isabel Carriedo Mompín*]). Probablement, la diferència més evident entre aquest supòsit i el de pagament de deute aliè del que ni se'n respon (almenys legalment; així, per no haver-se assumit a fi d'atendre les necessitats familiars de tipus ordinari o per obeir a aquesta finalitat però havent-se excedit del nivell de vida de la família) seria que només en el primer el cònjuge no-adquirent té un especial interès en el pagament. En cap cas, però, això arribaria a afectar la presumpció ni, en especial, el nexe o connexió lògica que cal apreciar entre el fet base (pagament de deute aliè i, en concret, del cònjuge) i el presumpte (així, l'absència d'ànim de reemborsament). Un cas diferent seria el de pagament pel cònjuge que, tot i ser deutor, no ha adquirit. La hipòtesi es planteja a propòsit de la possible adquisició del bé per part de només un dels cònjuges, sent així que al contracte precedent (així, una compravenda) haguessin intervingut els dos com a compradors. En la mesura en que la designació del *accipiens* i l'efecte real adquisitiu deriven del lliurament (que es produeix, fins i tot, malgrat la inexistència d'obligació prèvia: art. 1895 CC), és del tot possible que el dit lliurament es realitzi només a favor d'un d'ells i que, no obstant això, el preu s'hagi satisfet per ambdós (pel que fa a aquell lliurament, si es realitza en compliment d'un crèdit mancomunat indivisible, es veuria avalat pel règim propi d'aquesta modalitat de crèdits que, quant a la seva legitimació activa, s'identifica amb la pròpia de la solidaritat activa [BADOSA COLL, 1990, pp. 151-152]). El cas, malgrat encaixar en la lletra de l'art. 232-3.1 CCCat (adquisició onerosa per un dels cònjuges amb béns o diners procedents, en tot o en part, del patrimoni de l'altre), s'allunya de la hipòtesi real que s'hi contempla, que sembla demanar que el cònjuge que finança l'adquisició no en sigui també deutor. La raó seria que, en cas contrari, estaria satisfent o costejant deute propi, del pagament del qual no se'n pot derivar cap dret en termes de reintegrament o repetició enfront de l'adquirent (qüestió distinta és la que, en l'àmbit de les anomenades relacions internes, pugui sorgir arran de la configuració del crèdit al lliurament com a mancomunat indivisible i en la mesura en que aquell lliurament es verifiqui només a favor d'un dels cònjuges, esdevenint així únic adquirent de la cosa comprada no obstant per dos).

A propòsit de l'adquisició en virtut d'un dret d'opció de naturalesa real (o amb efectes *erga omnes*) i amb eficàcia també real (en tant que del seu exercici se'n deriven efectes adquisitius automàtics i sense necessitat de *traditio*), no pot parlar-se, estrictament, de pagament de deute aliè en aquells supòsits en què és un tercer qui satisfà la quantitat de la que depèn aquella eficàcia (sobre aquell caràcter automàtic, BOSCH CAPDEVILA [2008, p. 991]; qüestionant-lo, MONSERRAT VALERO [2010, p. 1145]). No hi ha deute ni tampoc activitat adreçada a satisfer-ne un (ni tan sols, com succeeix a l'art. 1895 CC, amb motiu de l'errònia creença de la seva existència). La conseqüència és que tampoc hi haurà pagament. Amb tot, l'expressió és la de "pagar el preu o la contraprestació" a l'art. 568-12 CCCat; d'aquí que el supòsit es

pugui entendre també inclòs a l'art. 232-3.1 CCCat i, això, tant si és el cònjuge adquirent el que satisfà el deute com si ho és l'altre. En aquest darrer cas, no procediran, pel que ja s'ha dit, els mecanismes de reintegrament propis del tercer que compleix amb obligació aliena (arts. 1158 i 1210 CC i concordants), sinó la via de l'enriquiment injust. En aquest context, la importància de l'art. 232-3.1 CCCat rauria, precisament, en presumir la causa de l'enriquiment que, per això, deixaria de ser injust.

L'objecte del pagament és, a l'art. 232-3.1 CCCat, "la contraprestació". Queda al marge de la norma, doncs, el pagament de qualsevol altre deute que, malgrat assumir-se amb motiu o com a conseqüència d'una adquisició, ho hagi estat en un concepte diferent al de contraprestació o preu (així, per exemple, el cost del transport de l'art. 1465 CC, el cost d'instal·lació del bé, les despeses necessàries en el supòsit descrit a l'art. 568-10.3 CCCat o, al marge del preu, qualsevol de les despeses relacionades a l'art. 328 CDCC).

D'altra banda, la lletra de l'art. 232-3.1 CCCat pressuposa que la contraprestació s'ha satisfet en tota la seva integritat i, tota ella, amb béns o diners procedents del cònjuge no-adquirent. Amb tot, és perfectament possible aplicar-lo també en supòsits de pagament parcial o en aquells en què, sent íntegre o no, només parcialment ho ha estat amb recursos procedents de patrimoni aliè. La referència expressa, a l'art. 232-3.1 CCCat, a una contraprestació no dinerària ("béns o diners") no només confirma la seva aplicació en cas d'adquisicions oneroses procedents de contractes diferents de la compravenda (així, un de permuta), sinó també en casos de compravenda en què el cònjuge adquirent intervé com a venedor, adquirint a títol onerós els diners en què consisteix el preu i lliurant, en contrapartida, un bé procedent del patrimoni del seu cònjuge.

La referència expressa a "béns", com a possible contraprestació, és una novetat del CCCat. Amb tot, la sola menció a "diners" als precedents de l'art. 232-3.1 CCCat ja va ser objecte d'una interpretació extensiva per la doctrina, entenent-se aplicable a tota contraprestació onerosa (MIRAMBELL, 1995, p. 192). D'altra banda, el precepte no sembla excloure que, com a contraprestació, s'hi contempli la renúncia del dret que el cònjuge no-adquirent pugui tenir davant del tercer transmitent (o, amb similars efectes, la condonació del deute d'aquest últim envers el primer). Tampoc que es comprometi, pel cònjuge adquirent, l'activitat del no-adquirent o que, havent-se obligat el primer a un fer no personalíssim, s'acabi satisfent pel cònjuge no-deutor com a tercer. En aquests casos, no obstant, possiblement serà més acurat parlar de presumpció de gratuïtat que de donació (encara que només sigui perquè el cònjuge adquirent no adquireix res del finançador: art. 531-7 CCCat).

La procedència acreditada de la contraprestació satisfeta deixa al marge de la norma els supòsits de procedència dubtosa. La impossibilitat de vincular aquells recursos o diners al patrimoni del cònjuge no-adquirent pot acabar perjudicant més a aquest últim que als seus creditors, si resulta aplicable en benefici d'aquests (art. 231-12.1 b CCCat). A la seva empara, havent-se declarat el concurs del cònjuge no adquirent i havent-se produït l'adquisició per l'altre durant l'any previ a aquella declaració, es presumirà "la donació de la meitat". D'aquesta manera, mentre que el concursat no podrà pretendre res del seu cònjuge, sí que podran els seus creditors; així, actuar sobre la donació presumpta de la meitat, ja s'entengui referida al bé (CORTADA CORTIJO, 2011, p. 229), ja ho sigui a la contraprestació satisfeta (AMETLLA CULÍ, 2011, p. 579).

2.2.2. El fet presumpte

"Es presumeix la donació" (art. 232-3.1 *in fine* CCCat), s'entén, del cònjuge no-adquirent al que sí

que va adquirir i, s'entén, dels recursos lliurats per a satisfer el preu o contraprestació. Això últim, avalat pels precedents, descarta l'alternativa de considerar que el que realment es va donar va ser el bé adquirit.

> Amb una més clara referència a la contraprestació procedent de l'altre cònjuge, l'art. 21 CDCC (després de la reforma de 1993) presumia "la seva" donació. L'art. 39 CF i, ara, l'art. 232-3.1 CCCat substitueixen l'adjectiu per l'article donant entrada, teòricament, a la possibilitat d'identificar l'objecte donat amb el bé adquirit (no obstant això, certament, a la versió oficial del text en català el pronom "se'n" gairebé ho descarta; vegeu, també, Preàmbul Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, III, c, par. 8è: "Es manté el principi…, tradicionalment reforçat amb la presumpció de donació de la contraprestació"[DOGC núm. 5686, de 5.8.2010]). Contràriament, pel cas d'entendre's que allò que s'ha donat és el bé, seria aleshores possible donar explicació del supòsit. O bé entenent que el que realment es presumeix donat és la contraprestació però que, per les raons que siguin, la presumpció legal es projecta sobre el bé adquirit. O bé veient el supòsit com un cas de doble simulació, subjectiva i objectiva, en un intent d'evidenciar que allò que va succeir fou que qui va transmetre va ser l'identificat com a cònjuge no-adquirent i que ho va fer a títol de donació; probablement, prèvia adquisició onerosa procedent de tercer (ambdues lectures són les que es proposaven a tall d'interpretació de l'art. 12 CF per ARNAU RAVENTÓS [2006, pp. 77 i ss]; aquest últim i a diferència de l'art. 232-3.1 CCCat, es presentava, no com una norma de règim econòmic, sinó de protecció a tercers i en virtut de la qual la presumpció de donació requeia, sens dubte, sobre el bé adquirit). Hi hauria una tercera explicació possible: entendre que va ser realment el cònjuge finançador qui va adquirir el bé per subrogació real i que després el va transmetre per donació a l'altre. Precisament, és aquesta interpretació la que la jurisprudència ha tingut cura de descartar, primer, a l'empara dels arts. 49 *in fine* i (després de la reforma de 1993) 21 CDCC; més tard, del art. 39 CF. Vegeu la STSJ Catalunya, Secc. 1a, 10.5.1993 (RJ 1993\6323*; MP: Jesús Corbal Fernández*), a propòsit de la pretensió del marit adreçada al reconeixement de la titularitat exclusiva d'un immoble i emparada en el fet d'haver costejat íntegrament l'adquisició. El Tribunal, molt contundentment, assenyala que: "ni antes, ni ahora, sería de aplicación el principio de la subrogación real, contemplado en el adecuado sentido de presumir que el que pone el dinero (el titular del mismo, no necesariamente el que paga) es el que adquiere, o mejor dicho, se presume que adquiere". Per la seva banda, la STSJ Catalunya, Secc. 1a, 5.3.1998 (RJ 1998\10049; *MP: Lluís Puig i Ferriol*) revoca la dictada en segona instància, que havia reconegut a la muller la cotitularitat de les finques comprades pel marit tal vegada que ella havia pagat part de preu. La STSJ Catalunya, Secc. 1a, 27.6.2002 (RJ 2002\10438; *MP: Núria Bassols Muntada*) es fa ressò de la jurisprudència anterior a propòsit de la reclamació de la muller per les quantitats invertides en l'adquisició de la vivenda familiar i un local de negoci. En tot cas, identificar l'objecte donat amb el bé adquirit (i no tant amb la contraprestació satisfeta) implica tant com presumir la falsedat del fet base (així, l'onerositat de l'adquisició).

a. L'antecedent: l'art. 21, 2n par. CDCC

Deixant enrere l'aïllada presumpció de l'art. 49 *in fine* CDCC (que ho era d'haver-se costejat l'adquisició amb diners privatius del cònjuge adquirent), la reforma duta a terme per la Llei 8/1993 va servir, de la mà de l'art. 21 de la mateixa CDCC, a un doble objectiu: d'una banda, al de descartar que la procedència aliena de la contraprestació satisfeta pogués arribar a incidir en la titularitat del bé. L'art. 49 CDCC, al no dir-ne res, permetia mantenir el dubte sobre si, en aquell cas, era possible distingir entre el "constar" com titular (fet base del què partia l'art. 49 CDCC) i el "ser-ho". A l'art. 49 CDCC no s'explicitaven, doncs, les conseqüències d'una eventual prova en contrari acreditativa de la procedència aliena de la contraprestació; així, el cònjuge que constava

com titular seguia sent-ho o pertocava aleshores reconèixer la titularitat material del cònjuge finançador? En aquest context, amb la reforma de 1993, si bé no arriba a confirmar-se expressament l'equivalència entre el "constar" i el "ser" titular (com sí que passa, segons s'ha dit, a l'art. 232-3 CCCat), sí que es desvincula de forma explícita la titularitat del bé de la procedència del preu. Com a mínim, ja no hi ha dubte de que el cònjuge el patrimoni del qual costeja l'adquisició, no pot reclamar-lo com a propi.

En segon lloc, l'art. 21 CDCC va encarar la qüestió de la situació subjacent al pagament amb diners procedents del patrimoni del cònjuge no adquirent. S'incorpora així una presumpció que, en primer terme, ho és d'atorgament d'un negoci jurídic entre cònjuges. Es presumeix, doncs, el consentiment del finançador, a qui, si escau, pertocarà aportar prova de la seva inexistència o de l'apropiació indeguda d'aquells fons per l'adquirent. En segon lloc, i essent possible presumir-ne qualsevol altre, es va presumir realitzada una donació.

> Abans de la reforma de 1993, la jurisprudència exigia la prova de l'*animus donandi* a fi d'entendre's realitzada una donació entre cònjuges; en cas contrari, i a manca de qualsevol altra evidència, es reconeixia un crèdit a la restitució de l'import lliurat (STSJ Catalunya, Secc. 1a, 31.1.1994 [RJ 1994\4587; *MP: Jesús Corbal Fernández*]). Adquirida una vivenda per ambdós cònjuges però havent satisfet el preu només el marit, se li reconeix, d'ençà el pagament, un crèdit a la restitució (STSJ Catalunya, Secc. 1a, 5.3.1998 [RJ 1998\10049; *MP: Lluis Puig i Ferriol*]).

b. L'àmbit d'aplicació de l'art. 232-3.1 CCCat: les relacions entre cònjuges

L'art. 232-3.1 CCCat, es pot al·legar per tercers? Així, per exemple, pels creditors del cònjuge finançador i a fi d'atacar directament la donació presumpta o pretendre-la inoponible (art. 531-14 CCCat). Tradicionalment, la norma general que acompleix l'anticipada funció de protecció de tercers (així, creditors, legitimaris…) davant els negocis celebrats entre cònjuges, és el 231-11 *in fine* CCCat (al seu torn, a l'art. 232-3.1 CCCat el punt de referència serien les relacions internes entre els cònjuges; explicitant que era aquesta la relació entre els arts. 11 i 39 CF [PUIG I FERRIOL, 2000, p. 222]). L'art. 231-11 CCCat, el contingut del qual va molt més enllà del que n'avança la seva rúbrica, acaba establint que, en cas d'impugnació judicial, correspon als "cònjuges" la prova del "caràcter onerós de la transmissió". La disposició, per tant, té sentit en el context d'un procediment judicial instat per tercers en els que es denunciï la falsedat de la causa onerosa del negoci que opera o justifica la transmissió. No incorpora cap presumpció, sinó que es limita a establir una norma relativa a la càrrega de la prova, invertint-la. En tot cas, a manca d'activitat probatòria suficient per part dels cònjuges, el que s'hauria d'entendre acreditat no seria tant, i necessàriament, una donació (com succeeix a l'art. 232-3.1 CCCat) sinó una transmissió "no onerosa".

> Certament, rubricat només "Llibertat de contractació", l'art. 231-11 CCCat reitera la dels cònjuges a transmetre's béns i drets "per qualsevol títol" i a atorgar entre ells qualsevol mena de negoci jurídic (no obstant això, advocant per una interpretació restrictiva de la norma i limitant-la, a l'empara d'aquella mateixa rúbrica, a la llibertat d'atorgar qualsevol tipus o espècie de contracte: PUIG I FERRIOL, 2011, p. 211). Els seus precedents arriben a l'art. 12 CDCC i, després de la reforma de 1993, a l'art. 18 CDCC el text dels quals pràcticament reprodueix, després, l'art. 11 CF. En concret, i a propòsit de la prova de

l'onerositat, la limitació de la norma a les transmissions (iniciada amb l'art. 18 CDCC) s'explicaria en un intent de facilitar als tercers creditors la prova de la gratuïtat només d'aquells actes que, per disminuir el patrimoni del deutor, objectivament els són perjudicials (CASANOVAS MUSSONS, 1995, p. 161). Des d'aquesta perspectiva, la solvència del deutor podria veure's amenaçada en casos de transmissió, no sols de la propietat (PUIG I FERRIOL, 2011, p. 212), sinó també de qualsevol altre dret patrimonial, ja sigui personal, ja sigui real. En el cas d'un préstec entre cònjuges, sens dubte caldrà parlar també de transmissió (art. 1753 CC), però no de disminució de patrimoni del prestamista tal vegada que, en el dit patrimoni, també pertocarà ara comptabilitzar el crèdit a la restitució. El supòsit no es preveu a l'art. 231-11 CCCat que regiria, només, en els d'impugnació per falsedat de la causa onerosa. Defensat pels cònjuges l'atorgament entre ells d'un préstec gratuït, i impugnat pels creditors en un intent de desvelar que allò que s'ha realitzat és una donació, és evident que la gratuïtat de la transmissió no s'arriba a discutir, sinó el tipus de negoci del que s'ha fet ús. En aquest cas, no pertoca parlar de la prova de l'onerositat (ni, molt menys, té sentit invertir-la). Regiran, doncs, les regles generals en matèria de càrrega de la prova (art. 217 LEC). En aquest context, interessarien dos comentaris més: primer, que lògicament no sols les transmissions gratuïtes poden perjudicar als creditors. Passa, simplement, que l'art. 231-11 CCCat només es fixa en aquest cas (art. 1297 *a contrari* CC; art. 71.3 LC). Segon, que queden també al marge del precepte els supòsits de falsa onerositat de l'adquisició derivada, per exemple, d'un dret d'adquisició preferent. Certament, i al marge del negoci -entre cònjuges- de constitució i transmissió del dret (així, una opció), l'adquisició derivada del seu exercici escapa de la idea de transmissió, que no n'hi ha, i, en conseqüència, de l'àmbit d'aplicació de la norma.

D'altra banda, s'ha dit que l'art. 231-11 CCCat no incorpora cap presumpció de donació (defensant que ho eren les previstes als arts. 11 CDCC i 11 CF, vegeu, respectivament, VIRGILI SORRIBES [1962, p. 55] i VAQUER ALOY [1999, p. 1534]). Al contrari, es tracta d'una norma en matèria de càrrega de la prova, que atribueix la de l'onerositat als cònjuges (STSJ Catalunya, Secc. 1a, 28.12.1993 [RJ 1993\10203; *MP: Luis M. Díaz Valcárcel*]; servint-se d'un argument més tècnic: PUIG I FERRIOL, 2011, p. 214. Defensa l'autor que: "no pot qualificar-se de presumpció, per quant les presumpcions legals es donen en la fase anterior, és a dir, en la fase de fixació dels fets; amb la conseqüència que, quan s'arriba a la càrrega de la prova, els fets afavorits per la presumpció legal ja han estat acreditats i, per tant, és inútil i irrellevant el problema de la càrrega de la prova"). Quan pertocaria als demandants aportar-la (art. 217.2 LEC), l'art. 231-11 CCCat distribueix la dita prova en perjudici dels cònjuges demandats (art. 217.5 LEC). Si no es facilita, la transmissió s'entendrà gratuïta, però sense que s'arribi a presumir, en aquest cas i necessàriament, que ho hagi estat per causa de donació (essent possible, també, que hagi obeït a un contracte unilateral, gratuït i atípic en la virtut del qual un dels cònjuges es va obligar a transmetre, i va transmetre, a l'altre un bé de la seva propietat). Això últim pot tenir especial interès si es planteja a propòsit dels diferents mecanismes d'impugnació, que ho poden ser: o bé exclusivament de la donació, o bé de la causa gratuïta i, en conseqüència, poden estendre's a tots els negocis que en participin (quant a la inoponibilitat de les donacions de l'art. 531-14 CCCat, vegeu, presentant-la com un efecte legal de la causa gratuïta: DEL POZO *et al.* [2008, p. 80]). La importància de la qüestió que s'ha plantejat (la de si l'art. 231-11 CCCat incorpora una presumpció de gratuïtat -o, fins i tot, de donació-, o només una regla de prova), s'explicaria perquè, presumida una donació, els tercers perjudicats podrien atacar directament el negoci presumpte. En qualsevol altre cas (així, es creu, en el de l'art. 231-11 CCCat), aquells haurien d'acreditar, en primer terme, que el negoci aparentment onerós no ho és en realitat; d'aquí la necessitat d'impugnar-lo per simulació relativa a la causa onerosa, encara que amb el particular benefici processal de recaure sobre els demandats la prova de l'onerositat. Des d'aquesta perspectiva, i sent així que la impugnació judicial de l'art. 231-11 CCCat és només la que obeeix a aquella falsa onerositat (CASANOVAS MUSSONS, 1995, p. 164), resultarà que, tractant-se d'una nul·litat absoluta (art. 1276 CC), l'acció corresponent no caducarà. I, això, sens perjudici que aquesta primera acció s'interposi acumulada a una altra: així, per exemple, a la pauliana de l'art. 1111 CC o a la declarativa d'inoponibilitat de l'art. 531-14 CCCat (al contrari, vinculant el termini de l'acció impugnatòria de l'art. 231-11 CCCat, entre altres, al termini per fer valer la inoponibilitat de l'art. 531-14 CCCat, PUIG I FERRIOL [2011, p. 217] i CORTADA CORTIJO [2011, pp. 225-226]).

En fi, una lectura conjunta dels arts. 231-11 i 231-12 CCCat reblaria la interpretació que es defensa. Si la "impugnació judicial" de la que tracta el primer pogués identificar-se amb l'exercici de qualsevol acció (i no sols amb la de simulació) l'èxit del qual demanés de la prova de la gratuïtat de la transmissió, sent així que el precepte servís precisament per excusar als demandants d'aquesta prova atribuint als cònjuges la de l'onerositat, llavors sí que caldria identificar l'art. 231-11 *in fine* CCCat amb una presumpció de gratuïtat. El legislador no l'hauria formulat directament (com si digués: "les transmissions entre cònjuges es presumeixen gratuïtes") sinó que, sent iuris tantum, ho hauria fet per mitjà d'una de les seves conseqüències processals, així: atribuint a la part perjudicada la possibilitat d'aportar prova en contra. Succeeix, però, que el CCCat confirma la voluntat de reservar la presumpció de donació per als supòsits, més greus, d'insolvència declarada i només si concorren determinades circumstàncies (així, les de l'art. 231-12 CCCat).

La perspectiva des de la que, respectivament, els arts. 231-11 *in fine* i 232-3.1 CCCat contemplen la transmissió entre cònjuges és molt distinta. En el primer, davant la transmissió que els cònjuges mostren com a onerosa, es facilita la prova de la gratuïtat als creditors. En el segon, el litigi es preveu que sorgeixi entre els mateixos cònjuges: davant de la possible pretensió del finançador, el precepte reacciona presumint que hi va haver transmissió al cònjuge adquirent i que, a més, va obeir a donació. No es creu que els creditors puguin recórrer a la norma ni als efectes d'atacar el negoci presumpte, ni als de pretendre que els sigui inoponible. La raó seria, novament, l'art. 231-12.1.a CCCat. S'hi reserva la presumpció de donació per al cas d'adquisició onerosa i contraprestació procedent del patrimoni del cònjuge no adquirent (com passa també a l'art. 232-3.1 CCCat), sempre i quan la dita adquisició s'hagi produït durant l'any anterior a la declaració de concurs d'aquest últim. En cas de facilitar-se als creditors l'accés a l'art. 231-3.1 CCCat a fi d'al·legar, a favor seu, la presumpció de donació en tot supòsit d'adquisició onerosa amb contraprestació procedent del cònjuge no adquirent, els requisits addicionals previstos en l'art. 231-12 CCCat mancarien, en el marc del règim de separació, de tota utilitat.

A diferència de l'art. 78.1 LC, l'art. 231-12 CCCat ni limita subjectivament el seu àmbit d'aplicació a la declaració de concurs de persona casada en règim de separació ni la presumpció es presenta, objectivament i expressament, "en benefici de la massa". D'entendre's que la presumpció de donació de l'art. 232-3.1 CCCat és també al·legable pels creditors i que ho és en tot cas (i no sols en situació d'insolvència declarada) i moment (al marge del temps de l'adquisició), hom podria defensar que en el règim de separació l'art. 231-12 CCCat queda del tot desplaçat. En conseqüència, l'àmbit d'aplicació d'aquest últim es veuria reduït a la declaració de concurs del deutor casat sota un règim (qualsevol) diferent al de separació. Aquesta lectura, però, podria arribar a ser contraproduent per al mateix creditor del casat en separació. Descartar l'aplicació de l'art. 231-12 CCCat podria implicar, per exemple, desconèixer la presumpció de donació de la meitat de la contraprestació satisfeta en aquells casos en què no fos possible acreditar-ne la procedència (art. 231-12.1.b CCCat). Això, tret que s'entengués que, precisament, és amb aquesta darrera presumpció (i no amb la contemplada a l'art. 231-12.1.a CCCat) amb la que s'intensifica la protecció dels creditors per al cas d'insolvència declarada del deutor casat en règim de separació.

En el context de la legislació anterior, es va defensar la subjecció de la presumpció de donació al règim previst als arts. 18.1 *in fine* i 2 CDCC (MIRAMBELL ABANCÓ, 1995, p. 194).

I si als creditors no els és possible recórrer a l'art. 232-3.1 CCCat a fi de beneficiar-se de la presumpció de donació que s'hi estableix, què fer davant la utilització dels recursos del deutor

per a satisfer el deute del seu cònjuge? En aquest context, caldrà interposar una acció declarativa que constati que allò que s'ha atorgat és una donació o, si escau, un negoci gratuït que, en la mesura que esdevingui perjudicial o fraudulent, serà al seu torn rescindible o inoponible. Una darrera qüestió que plantejaria el supòsit seria si, interposat un plet amb aquella finalitat, regiria també la regla d'inversió probatòria prevista a l'art. 231-11 CCCat. Altrament, si seran els cònjuges els que hauran de provar l'onerositat del negoci i no tant els demandants la seva naturalesa gratuïta. Passa, però, que no sempre caldrà una prova sobre aquest particular (per exemple, quan davant la pretensió declarativa d'un negoci de donació, els demandats al·leguin que allò que s'ha atorgat és un simple préstec gratuït).

La situació anterior pot incomodar especialment el cònjuge adquirent. Perquè mentre la presumpció de donació de l'art. 232-3.2 CCCat, sens dubte, el situa en molt bona situació davant l'eventual pretensió restitutòria del seu cònjuge, davant la declarativa dels creditors d'aquest últim segurament convingui millor als seus interessos defensar que allò que es va atorgar va ser un negoci onerós.

D'altra banda, en aquells supòsits en què sigui el propi cònjuge no-adquirent però finançador qui satisfaci directament deute aliè ("sense ànim de reclamar[la]", art. 1894, par.1r, *in fine* CC), serà possible també impugnar directament el pagament per raó de la seva inexigibilitat al temps de satisfer-se (s'entén, respecte al dit cònjuge no deutor i s'entén, també, sempre que concorrin els requisits addicionals de frau, perjudici…que exigeixi l'acció impugnatòria que es tracti). L'argument el proporcionen articles com l'art. 1292 CC o l'art. 71.2 LC. Ambdós preceptes exigeixen, però, o bé que aquell pagament hagi incrementat la situació d'insolvència del deutor (per tant, no és possible que simplement l'hagi provocat: BADOSA COLL, 1990, p. 214), o que s'hagi realitzat durant l'anomenat període sospitós. Més enllà d'aquestes circumstàncies, el pagament, encara que inexigible (en especial, per raó d'un termini encara no vençut), és un acte degut i en conseqüència no pot atacar-se pels creditors encara no satisfets. Succeeix, però, que aquells preceptes contemplen la situació del deutor que satisfà els seus deutes abans del seu venciment. El supòsit que ara es planteja és, contràriament, el del tercer que satisfà deute aliè, sigui o no exigible al deutor. Tal vegada que tractant-se d'un tercer l'acte de compliment és un acte espontani (o no degut), es creu que ha de ser possible la seva impugnació si, com a efecte, el seu patrimoni queda en estat de no poder satisfer els seus propis deutes (art. 1111 CC). La inexigibilitat del pagament i la situació d'insolvència patrimonial que genera aquella satisfacció justificarien aquella impugnació, prescindint de *l'animus donandi* del tercer respecte del seu cònjuge deutor. El cert és, però, que si no s'arriba a provar això últim tampoc podrà provar-se aquella insuficiència patrimonial: a manca d'aquell "ànim de no reclamar" (o de la seva prova), la contraprestació satisfeta haurà donat pas, en el patrimoni del *solvens* i llevat supòsits com el de l'art. 1158 *in fine* CC, a un crèdit per igual import o prestació.

c. El règim de la donació presumpta. La prova en contrari

D'una banda, la mecànica de l'art. 232-3.1 CCCat avala el rebuig de l'expedient de la subrogació real, en la virtut del qual el bé adquirit ocuparia el lloc, en el patrimoni que va costejar l'adquisició, de la contraprestació satisfeta. La raó és, novament, que la contraprova del fet presumpte en cap cas modificarà la titularitat del bé; així, tant si s'acredita que el negoci atorgat entre els cònjuges és d'un altre tipus (així, un préstec), com si el que es prova és que no hi va haver ni negoci ni transmissió i sí, en canvi, apropiació indeguda. En segon lloc, el precepte permet reviure, per al cas de contraprestació procedent del patrimoni del cònjuge no-adquirent, la presumpció de l'art. 49 *in fine* CDCC i, després de la reforma de 1993, de l'art. 21, par. 2n, del

mateix text. Així, i més enllà de presumir-se una donació entre cònjuges, s'està també presumint que l'adquisició del bé s'ha finançat amb béns privatius de l'adquirent (que ho serien des que, presumiblement, li van ser donats pel seu cònjuge). La importància d'això últim és que tanca el pas a tota possible reclamació, de naturalesa reivindicatòria, de qui apareixia simplement com presumpte finançador i adreçada al receptor del preu. L'excepció al pagament amb béns que, per raó de la presumpció, s'entenen privatius de l'adquirent seran aquells supòsits en què el cònjuge finançador satisfà el preu com a tercer i sense ànim de reclamar a l'adquirent en via de tornada; des del punt de vista d'aquest últim, la seva adquisició s'haurà costejat amb béns o recursos aliens. D'altra banda, mentre que el rebuig a la subrogació real s'adiu plenament amb el sistema general d'adquisició de titularitats reals, la presumpció de donació sí que és, estrictament, una norma matrimonial. Si el finançador no és el cònjuge, no regeix cap presumpció legal de prèvia donació del preu a l'adquirent, ni tan sols de prèvia transmissió.

Vist que la presumpció de donació de l'art. 232-3 CCCat no és al·legable pels creditors, ni poden pretendre que la disposició els sigui inoponible (art. 531-14 CCCat), ni atacar-la d'altra manera per causa de frau o perjudici; malgrat això, sí que podrà revocar-se, a iniciativa del cònjuge presumptament donant, si hi ha causa legal per fer-ho (arts. 531-9.4, 531-15 i 231-14 CCCat).

> Si escau, els béns o recursos presumptament donats seran atribucions patrimonials imputables a la compensació econòmica per raó de treball d'acord amb l'art. 232-6.2 CCCat.

D'altra banda, tractant-se d'una presumpció iuris tantum (art. 385.3 LEC), la de l'art. 232-3.1 *in fine* CCCat admet prova en contrari. Pertocarà aportar-la a aquell a qui perjudiqui: així, al presumptament donant que reclama, per exemple, la restitució del capital que, segons ell, només es va prestar; així, pel presumptament donatari, que s'oposa a la revocació pretesa pel primer. Objectivament, aquella prova podrà recaure tant sobre el fet presumpte, acreditant-se que no és cert, com sobre l'enllaç que ha de mitjançar entre aquest últim i el fet base (art. 385.2 LEC; negant en tot cas aquesta possibilitat: GARBERÍ LLOBREGAT, 2001, p. 262). Aquest enllaç és el vincle o nexe causal o lògic que, a partir de màximes de l'experiència o índexs de probabilitat, permet concloure que si s'ha produït el fet base, probablement també s'ha produït el presumpte. Sent això així, en el context de l'art. 232-3.1 CCCat, podria plantejar-se si es dóna aquella connexió en cas de separació legal o de fet al temps de la donació presumpta. I això, lògicament, perquè en situació de crisi matrimonial decau la probabilitat, no sols de que l'atribució obeeixi a donació, sinó fins i tot de tota causa gratuïta (així, també, de que allò que s'ha atorgat sigui, per exemple, un préstec sense interès; vegeu, no obstant això, l'art. 231-11 *in fine* CCCat que, a propòsit de la regla d'inversió de la càrrega de la prova, no exclou del seu àmbit les transmissions entre cònjuges separats).

> L'excepció sí que la recull, per exemple, l'art. 231-12.3 CCCat que, com ja succeïa a l'art. 12 CF, es remet al temps de l'adquisició (l'art. 78.2 LC no concreta si els cònjuges han d'estar separats al temps de la posada a disposició dels recursos a favor de l'adquirent, al temps de l'adquisició o al temps del pagament al tercer; optant per la primera de les possibilitats [ARNAU RAVENTÓS, 2006, p. 86]). En cas de separació judicial, la qüestió no caldrà plantejar-la: en la mesura en que la sentència hagi provocat l'extinció del règim econòmic, haurà quedat descartada també l'aplicació del precepte. El problema, però, consisteix precisament en determinar si tota sentència d'aquell tipus produeix aquell efecte. Entre

altres, va ser en el context de l'art. 23 CDCC, relatiu a l'anomenada compensació econòmica per raó del treball, que es va suscitar l'interrogant i, això, tal vegada que el precepte lligava aquell dret a l'extinció del règim per separació judicial, divorci o nul·litat (GETE-ALONSO CALERA, 1996, p. 627). L'art 41 CF era menys rotund. Demanava també que la situació ho fos de separació judicial, divorci o nul·litat, però sense fer en cap cas referència als seus efectes respecte al règim (vegeu, emparant-se en aquella polèmica a fi de justificar la nova redacció, PARA MARTÍN [1999, p. 14]; entenent que la separació judicial comporta sempre l'extinció *ex lege* del règim, ORTUÑO MUÑOZ [2000, p. 235]). L'art. 232-5.1 CCCat permet reproduir de nou la qüestió. El motiu és que remet l'apreciació de l'increment patrimonial experimentat pels cònjuges al "moment de l'extinció del règim per separació... ". En aquest nou context, ni tan sols són determinants els arts. 233-2.3 c i d, i 233-4.2 CCCat. Ambdós preceptes confirmarien que en cas de separació judicial no hi ha, almenys, necessitat de liquidar el règim. Així, els extrems de l'art. 233-2.3 CCCat es podran incloure en el conveni només "si procedeix"; per tant, és ben bé possible que els cònjuges, malgrat la crisi, optin per no liquidar-lo. I el mateix podria assenyalar-se dels pronunciaments que relaciona l'art. 233-4.2 CCCat, que exigeixen que siguin sol·licitats per algun dels cònjuges. També és cert que la possibilitat de sol·licitar o no aquella liquidació tampoc és argument irrefutable a favor de la no extinció automàtica del règim. Podria succeir que, extingit necessàriament, els cònjuges no sol·licitessin la liquidació, per exemple, per no tenir res a liquidar o per preferir deixar-ho per a un procediment posterior (ROCA TRIAS, 2008, p. 663).

La prova en contrari del fet presumpte pot plantejar-se a fi d'acreditar la inexistència de transmissió entre cònjuges (així, perquè l'adquirent es va apropiar indegudament dels fons del seu cònjuge) o que, tot i produïda, va obeir a un negoci onerós o, fins i tot, gratuït però diferent d'una donació o, en fi, que es va realitzar *solvendi causa*.

Atesa la naturalesa solemne de la donació (art. 531-12 CCCat), la prova en contrari podria perfectament anar dirigida a acreditar la inexistència de negoci per manca de forma. Si a això s'hi sumés una pretensió per causa d'onerositat (així, per exemple, adreçada a obtenir els interessos per la quantitat emprada en el pagament), la qüestió que es plantejaria seria la de si hauria de ser el cònjuge demandat el que hauria d'acreditar, si escaigués, la gratuïtat del negoci o el demandant aquella onerositat. La primera possibilitat s'adiria amb la jurisprudència que exigeix la prova de la naturalesa gratuïta del negoci (SAP Barcelona, Secc. 16a, 27.5.2010 [JUR 2010\290654; *MP: Jordi Seguí Puntas*], entre d'altres). La segona podria recolzar-se fins i tot en el mateix art. 232-3.1 CCCat. Si s'hi presumeix la donació, no semblaria lògic que, provada la inexistència d'aquell negoci per manca de forma, subsisteixi no obstant la presumpció de transmissió i, en concret, de transmissió gratuïta?

D'altra banda, i pel cas de que hi fossin, l'obligació de restitució o qualsevol altra (així, la de pagament d'interessos) es veuran afectades per l'art. 121-16.b CCCat, relatiu a la suspensió de la prescripció en les pretensions entre cònjuges.

2.2.3. De la presumpció de donació entre cònjuges a propòsit de l'adquisició onerosa d'un bé…a la presumpció de gratuïtat en els negocis entre cònjuges?

Si els que s'han assenyalat són els elements i la mecànica de la presumpció prevista a l'art. 232-3.1 *in fine* CCCat, aleshores succeeix que queden al marge del seu àmbit d'aplicació supòsits molt propers al que s'hi descriu.

Per causa de la temporalitat de l'adquisició, quedarien literalment fora de la norma les adquisicions prèvies a la celebració del matrimoni sent així que el pagament es satisfà un cop

casats i amb béns o diners procedents del patrimoni de qui ja és cònjuge de l'adquirent. En cas d'adquisició constant matrimoni i, no obstant això, de pagament previ al vincle, la no aplicació de la presumpció quedaria formalment justificada perquè, al temps d'aquell pagament, la contraprestació no es va satisfer amb béns o diners "de l'altre cònjuge".

> Vegeu la SAP Barcelona, Secc. 14a, 4.11.2003 (JUR 2004\4484; *MP: Mª Eugenia Alegret Burgès*). El litigi troba el seu origen en l'adquisició d'un negoci de farmàcia, posat a nom de la dona però costejat per aquesta i per la seva parella. Descartada l'aplicació de l'art. 39 CF perquè la situació es va produir abans del matrimoni, es defuig també del recurs a l'expedient de la subrogació real a fi de justificar la cotitularitat del negoci, però "sense perjudici dels drets de crèdit que poguessin existir".

Per raó del que s'adquireix onerosament, que han de ser "béns" (art. 232-3.1 CCCat), escaparien també de la presumpció els serveis satisfets a un dels cònjuges però costejats amb béns o diners procedents del patrimoni de l'altre. I amb més motiu els supòsits en què també procedeixen d'aquell patrimoni els recursos emprats per satisfer un deute que no es correspon amb el pagament d'una contraprestació per l'adquisició d'un bé (així, el pagament d'una sanció administrativa, d'una indemnització per responsabilitat extracontractual...). En el context de l'art. 232-3 CCCat l'exclusió d'aquestes i altres hipòtesis (així, de pagament pendent encara l'adquisició) està del tot justificada. La finalitat del precepte, així com la de l'art. 232-4 CCCat, és la de contribuir a la determinació dels béns que integren el patrimoni d'un i altre cònjuge, de manera que la resta de relacions que sorgeixen al marge de l'adquisició d'un bé són alienes a la finalitat i al text de la norma.

> Si escau, la raó de ser de l'art. 232-3.1 *in fine* CCCat (que descarta tota idea de subrogació real) permetria desestimar també tota pretensió que, cobejada pel cònjuge que ha finançat el preu degut pel seu cònjuge, ho fos de la titularitat del bé o l'exigibilitat del crèdit que es tingués davant d'un tercer. I, això, amb independència de que aquest últim dret s'adrecés al lliurament d'una cosa o a la prestació d'un servei (com si, per exemple, per haver pagat el cotxe comprat pel cònjuge però encara no lliurat, fos aleshores el finançador qui al legués tenir ell el dret a exigir-ne el lliurament i a obtenir la titularitat del bé).

Succeeix, però, que en un context de determinació de la composició del patrimoni propi de cadascun dels cònjuges, la pròpia presumpció de donació esdevé innecessària excedint, així, d'aquella finalitat. Al servei d'aquella determinació, n'hi hauria hagut prou amb la regla de la pertinença dels béns al cònjuge que consti com titular afegint-se, en el seu cas, que això succeeix així encara que la contraprestació procedeixi del cònjuge no-adquirent. Al incorporar-se la presumpció, s'incideix en un àmbit distint, així: el de les relacions entre cònjuges i s'incideix establint, no sols una presumpció de transmissió gratuïta, sinó, i en concret, de transmissió per causa de donació. En aquestes circumstàncies, i més enllà de l'argument de l'estricta i rigorosa literalitat de l'art. 232-3.1 CCCat, es fa difícil justificar la no aplicació d'aquella mateixa presumpció a tot supòsit de transmissió de béns entre cònjuges, amb independència de que allò que s'hagi transmès s'empri o no a propòsit d'una altra adquisició i, en especial, a fi de satisfer el seu preu o contraprestació. I es fa també difícil no derivar-ne, potser a tall de principi general, una presumpció de gratuïtat de tot negoci de finalitat no transmissiva atorgat entre cònjuges. En tot cas, el seu àmbit d'aplicació seria, estrictament, el de les relacions entre cònjuges.

L'existència d'una presumpció de gratuïtat com a principi general podria suggerir-se, més enllà de l'art. 232-3.1 CCCat, arran de l'art. 232-5.2 CCCat relatiu a la compensació econòmica per raó del treball realitzat per a l'altre cònjuge sense retribució o amb una retribució insuficient. A diferència del previst a l'art. 5.1 CF, el CCCat no recull aquella activitat com a forma de contribució al manteniment familiar (per bé que seria perfectament possible i vàlid un pacte en contrari; vegeu art. 231-6.1 CCCat). L'art. 235-5 CCCat ha defugit també de la necessitat de parlar, en cas de crisi matrimonial, de la desaparició retroactiva de la causa de l'enriquiment del cònjuge perceptor del treball, com en canvi suggeria l'art. 41 CF i la seva expressa referència a la situació d'enriquiment injust (ORTUÑO MUÑOZ, 2000, p. 238). Sent això així, es diria que l'art. 235-5.2 CCCat presumeix que aquella activitat es va realitzar gratuïtament (en tot o en part) i reacciona simplement, com a correctiu del règim, reconeixent al cònjuge treballador el dret a una compensació en aquells supòsits en què el patrimoni del perceptor del treball ha incrementat més que el seu. En aquest context, res impedeix que qui va treballar per a l'altre acrediti, destruint aquella presumpció, que ho va fer onerosament i, en conseqüència, reclami el que se li deu i que ho faci abans o després de la crisi matrimonial.

D'altra banda, per bé que l'estricta literalitat de l'art. 232-3.1 CCCat tampoc ho descarta, no sembla que es pugui aplicar a les adquisicions procedents del mateix cònjuge finançador. L'estratègia (així, que un d'ells faciliti a l'altre els fons amb què satisfer després al primer el preu per l'adquisició d'un bé) no sembla que pugui tenir gaire sentit. Sí, en canvi, davant de tercers: pot esdevenir un mecanisme a fi que les accions d'impugnació de la donació afectin al preu (que és el que s'entendrà donat; així, a l'art. 231-12.1 a CCCat) però no al bé. Per cert que en el context d'aquesta última disposició, és possible reproduir la qüestió apuntada a propòsit de les atribucions patrimonials entre cònjuges realitzades al marge de tota adquisició procedent de tercer. Mentre que la presumpció de donació prevista a l'art. 12 CF podia aplicar-se en casos d'adquisició onerosa procedent del cònjuge concursat, en el context de l'art. 231-12.1 CCCat el supòsit sembla que s'ignora. I de confirmar-se que en aquests casos no regeix, aleshores s'encamina als creditors a interposar la corresponent acció declarativa de donació (així, si el que succeeix és que, sense causa acreditada, la titularitat del bé consta ara a favor del no deutor) o, si escau, de simulació de la causa onerosa (donant-se entrada, en aquest cas, a l'art. 231-11 *in fine* CCCat).

Pel cas de considerar-se que no es pot parlar de presumpció de gratuïtat a propòsit de totes les relacions negocials entre cònjuges, les pretensions derivades d'una causa onerosa o gratuïta no acreditada es podran també resoldre a l'empara d'una presumpció judicial. En aquest sentit, vegeu la SAP Barcelona, Secc. 16a, 27.5.2010 (JUR 2010\290654; *MP: Jordi Seguí Puntas*) relativa la presumpció judicial d'onerositat a manca de prova de la gratuïtat de l'atribució en supòsits, com el del litigi, d'especial amistat entre les parts. Afirma el tribunal que: "puesto que la abstracción procesal de la causa es lícita (art. 1277 del Código civil) y que en los contratos de pura beneficencia la causa del mismo radica en la 'mera liberalidad del bien hecho' (art. 1274 del Código civil), es indudable que la concurrencia de circunstancias especiales (así, relaciones de parentesco o de intensa amistad) que autoricen a presumir la concurrencia de esta liberalidad sirven para desvirtuar la mencionada presunción judicial –de onerosidad-, que no legal. De hecho, en las ocasiones en que la controversia gira en torno a la naturaleza de la causa -gratuita u onerosa- de una atribución patrimonial sin respaldo contractual escrito, el Tribunal Supremo no autoriza a resolver sin más en función de la distribución de la carga de la prueba que sería acorde con dicha presunción judicial (reconocer el carácter oneroso de la operación por el mero hecho que el beneficiado, aun demandado, no pruebe el carácter liberal de la atribución), sino que manda valorar las tesis de una y otra parte y resolver en función de la convicción que se alcance en virtud del material probatorio, sin dispensar al demandante de la demostración de la causa onerosa por él postulada".

Per raó del vincle i del règim econòmic matrimonial, la presumpció legal de donació no regirà ni en el supòsit d'adquisició per un dels convivents no casats, sent així que el preu es va satisfer

amb diners procedents del patrimoni de l'altre, ni en cas de cònjuges subjectes a un règim diferent al de separació o participació (art. 232-13.2 CCCat). Amb tot, seria igualment possible valorar l'aplicabilitat teòrica de la norma sota la vigència de qualsevol règim que permeti, d'una manera o una altra, la coexistència de patrimonis privatius. En un context com aquest, és perfectament possible que es donin les circumstàncies descrites a l'art. 232-13.2 CCCat, així: la constància de la titularitat del bé a favor d'un dels cònjuges i, no obstant això, que el preu s'hagi costejat per l'altre. I en un context com aquest, és també possible que es plantegin els mateixos dubtes als que dóna resposta l'art. 232-3.1 CCCat, però en seu de separació.

> En aquest particular, i a propòsit del règim de comunitat, cal considerar especialment l'art. 232-32 c CCCat. S'hi estableix que són béns privatius "de cada cònjuge" "els adquirits per subrogació real d'altres béns privatius". Es diria que la norma contempla l'adquisició d'un bé per un dels cònjuges i a canvi de béns o diners propis. Així, el bé adquirit ocupa, en el patrimoni adquirent, el lloc de la contraprestació satisfeta. La qüestió que planteja l'art 232-32 c CCCat és si, per subrogació real, l'adquirent serà sempre el titular del patrimoni privatiu que ha costejat l'adquisició, encara que al contracte previ només hagi participat l'altre i hagi estat aquest darrer a qui se li hagi fet lliurament del bé.

2.3. La presumpció de titularitat compartida i a parts iguals indivises

L'art. 232-3.2 CCCat no té precedents. Incorpora una segona presumpció que, com a fet base, demana acreditar l'adquisició onerosa, constant matrimoni, d'un bé moble de valor ordinari destinat a l'ús familiar (Preàmbul III, c, par. 8è *in fine* Llei 25/2010). Aquests béns "es presumeix que pertanyen a ambdós cònjuges a parts iguals indivises, sense que prevalgui contra aquesta presumpció la mera prova de la titularitat formal". Si en el context de l'art. 232-3.1 CCCat, la titularitat formal prevalia sobre que pogués derivar del principi de subrogació real, a l'apartat 2n del mateix precepte la prevalença ho és de la titularitat material -que es presumeix que correspon a ambdós cònjuges en règim de proindivisió -enfront de la formal. Tractant-se de béns d'aquell tipus i naturalesa, no n'hi prou amb el fet de constar a nom d'un dels cònjuges per entendre que li pertanyen en exclusiva.

> Pensi's, per exemple, en la constància de la titularitat exclusiva d'un vehicle a motor als registres administratius corresponents (STSJ Catalunya, Secc. 1a, 28.11.2002 (RJ 2002\10924; *MP: Guillermo Vidal Andreu*). No obstant, en la majoria de casos el que hi haurà serà, com a molt, un comprovant de compra que, de fet, habitualment ho serà només de pagament del preu.

A l'art. 232-3.1 CCCat, i com ja s'ha dit, aquella titularitat formal tampoc és inqüestionable. Passa, però, que en aquell primer apartat el legislador té present un altre problema; així, no tant que el bé aparegui a nom de qui no va comprar (o no ho va fer en exclusiva), sinó en el que provoca el finançament aliè de l'adquisició. El cònjuge del què no en consta la titularitat no pot pretendre que es declari que el bé és seu amb l'argument de que va ser ell qui va pagar o costejar l'adquisició. Sens dubte, però, podrà demostrar que aquella titularitat formal no es correspon amb la real perquè, per exemple, va ser ell qui realment va adquirir. Succeirà, simplement, si no es tracta d'un bé moble de valor ordinari destinat a l'ús familiar, que ni tan sols regirà la presumpció de titularitat material a parts iguals indivises.

I si en el context de l'art. 232-3.1 CCCat la qüestió de rerefons que es vol tractar és la dita i no tant la de la manca de correspondència entre la titularitat formal i material del bé, a l'apartat 2n es prescindeix de la procedència de la contraprestació, i l'atenció se centra en aquella manca d'equivalència. La presumpció de l'art. 232-3.2 CCCat ho és, doncs, de titularitat material compartida i en règim de proindivisió (i, podria afegir-se, a parts iguals; art. 552.1.3 CCCat). Pel demés, i encara que, certament, la presumpció ho és de pertinença "a ambdós" i no tant de "adquisició per ambdós", es diria que el precepte té present, en primer terme, això últim; així, que varen ser ambdós cònjuges els qui, per igual, varen participar en el títol adquisitiu (així, ambdós van comprar i a ambdós se'ls va fer lliurament del bé).

La pertinença del bé a ambdós cònjuges només es presumeix. I la dita presumpció pot contradir-se aportant prova en contrari (Preàmbul Llei 25/2010, III, c, par. 8è *in fine*). No ho serà la de la constància de la titularitat només a favor d'un d'ells. De fet, en la majoria de casos aquella constància no serà tant una contraprova fallida (com, contràriament, sembla deduir-se del text legal; art. 232-3.2 *in fine* CCCat: "... sense que prevalgui contra la dita presumpció la mera prova de la titularitat formal"), sinó que servirà al mateix fet base. Així, en la majoria de supòsits, la prova de la titularitat formal es facilitarà als efectes d'acreditar l'adquisició onerosa constant matrimoni. De fet, l'art. 232-3.2 CCCat està pensant en supòsits en què, precisament, és aquella prova l'única que s'aporta a propòsit de l'adquisició.

> Com provar aquella adquisició sense provar, al mateix temps, qui són els adquirents? Si s'aconsegueix acreditar l'adquisició onerosa sense identificar els adquirents (així, per exemple, mitjançant un simple tiquet de compra sense cap referència addicional al comprador), llavors el supòsit s'haurà de resoldre fent ús de l'art. 232-4 CCCat. Si la prova de l'adquisició onerosa implica prova de la titularitat material (així, perquè consta qui va comprar i a qui es va fer el lliurament, i és només un dels cònjuges), s'hauria aportat quelcom més que "la mera prova de la titularitat formal", acreditant-se a qui correspon també la material i, en conseqüència, desvirtuant la presumpció. El seu àmbit natural d'aplicació, doncs, es redueix a aquells supòsits en què la prova de l'adquisició onerosa ho és, també, de la titularitat només formal (és a dir, en una prova de la constància del bé a nom d'un dels cònjuges com a titular).

Tampoc serà contraprova suficient la relativa al pagament del preu per o a càrrec de només un dels cònjuges o, si escau, per un d'ells en major proporció que l'altre. En les seves últimes conseqüències, defensar el contrari implicaria tant com defensar que la titularitat d'aquests béns ve donada per la titularitat de la contraprestació. Seria justament l'opció refusada de manera expressa a l'art. 232-3.1 CCCat sense que, pel demés, s'arribi a veure motiu o raó que podria justificar l'adopció d'un sistema diferent, quant a atribució o determinació de titularitats, en funció de la naturalesa i tipus de béns. Serà prova en contrari suficient la de la titularitat material: així, la que acrediti que només un dels cònjuges va participar en l'adquisició i que va fer-ho en nom propi.

> Per aquesta qüestió, vegeu BAYO DELGADO (2011, p. 688). Argumenta l'autor que la prova relativa a l'origen de la contraprestació permet reconduir el supòsit a l'apartat 1r de l'art. 232-3 CCCat; d'aquesta manera, si a la mera prova de la titularitat formal s'hi afegeix la relativa al pagament a càrrec del patrimoni del cònjuge titular, hom podrà concloure aleshores que el bé efectivament li pertany. Pel contrari, si el cas és de finançament aliè, llavors pertocarà aplicar la presumpció de donació de l'art. 232-3.1 *in fine* CCCat. El argument permet, però, dos comentaris: primer, que la primera de les regles que

recull el precepte (així, la de pertinença del bé en titular formal) no demana, en cap cas, que l'adquisició s'hagi autofinançat pel mateix adquirent; segon, que pel cas de titularitat formal d'un dels cònjuges, la prova del pagament a càrrec de l'altre no s'entén que afegeixi res als efectes de validar aquella titularitat i destruir la presumpció de pertinença a ambdós en proindivís. Això és el que passarà, segons s'ha dit, si s'aportés prova, per exemple, de que només un dels cònjuges va comprar i de que només a ell se li va lliurar el bé. Bastaria, sens dubte, als efectes de destruir tota presumpció d'adquisició conjunta i proindivís. Succeeix, segons s'ha apuntat també, que a l'art. 232-3.2 CCCat la presumpció ho és de pertinença a ambdós, sent així que això últim pot ésser perfectament compatible amb una adquisició, inicial, per un d'ells. L'art. 232-3.2 CCCat prescindiria de presumpcions intermèdies (així, per exemple, de donació posterior de la meitat al cònjuge inicialment no-adquirent), convertint de fet aquella presumpció en una regla d'atribució *ex lege* de titularitats de molt difícil contraprova (així, constant el bé a nom d'un dels cònjuges i havent-se provat que va ser ell qui el va comprar, cóm acreditar, a més a més, que ara l'altre no participa d'alguna manera en aquella titularitat?).

En coherència amb allò que s'ha afirmat a propòsit de l'art. 232-3.1 CCCat, de la presumpció de pertinença del bé en règim de proindivís ordinari no se'n poden valer els creditors als efectes, per exemple, d'agredir la quota de participació del cònjuge deutor. Òbviament, sí que en poden fer ús els cònjuges i, en especial, aquell que no consta com a titular formal; així, a fi d'exercir les facultats que li pertoquen com a comuner i, en concret, la de sol·licitar la divisió (art. 232-12 CCCat).

En el cas resolt per la STSJ Catalunya, Secc. 1a, 28.11.2002 (RJ 2002\10924; *MP: Guillermo Vidal Andreu*), la pertinença d'un vehicle a ambdós cònjuges, que el Tribunal considera acreditada malgrat constar només a nom de l'esposa, justifica i explica la legitimació processal del marit per a reclamar contra la venedora per incompliment contractual.

3. Titularitats dubtoses

A propòsit de la composició del patrimoni propi de cadascun dels cònjuges, l'art. 232-4 CCCat encara la qüestió de les titularitats dubtoses. En el dubte sobre a qui pertany un bé (així, perquè es desconeix qui n'és el titular o perquè la prova aportada és contradictòria), s'atribueix aquella titularitat a ambdós cònjuges en proindivís ordinari (i, en aplicació de l'art. 552-1.3 CCCat, a parts iguals). L'excepció serien els béns mobles d'ús personal d'un dels cònjuges que no siguin d'extraordinari valor i els que estiguin directament relacionats amb l'exercici de la seva activitat professional (mencionats, també, a l'art. 232-32 CCCat). En ambdós casos, la presumpció és de titularitat exclusiva a favor de l'usuari.

La qüestió pot plantejar-se també en un règim de comunitat. Com ja succeïa als precedents, els arts. 232-30 a 38 CCCat no inclouen una norma de tancament (absent també al CF; vegeu, sobre això, MARSAL GUILLAMET, 2000, p. 343).

Més enllà del dubte sobre la titularitat del bé, l'art. 232-4 CCCat no exigeix (com sí que fa l'art. 232-3 CCCat) ni que es tracti de béns adquirits durant el matrimoni, ni que la seva adquisició obeeixi a un títol onerós. Tampoc ho feia l'art. 40 CF. Pel contrari, l'adquisició constant matrimoni era un requisit a l'art. 49, par. 3r *in fine* (i, després, a l'art. 21, par. 3r) CDCC. I era lògic. Així, les

normes de règim econòmic pressuposen l'existència d'un vincle matrimonial i determinen el règim dels béns a partir d'aquell moment. Quedaria al marge d'aquesta lògica que, a l'empara de aquelles regles, s'intentés fixar la titularitat de béns adquirits amb anterioritat i que, a més a més, aquesta finalitat s'aconseguís reconeixent una titularitat proindivís entre els qui, al mateix temps de l'adquisició, no estaven casats. El cert és, però, que el supòsit és perfectament plantejable i que, literalment, l'art. 232-4 CCCat pot aplicar-se al cas (pensi's, per exemple, en una adquisició prèvia al matrimoni, avalada per un tiquet de compra, document de garantia…, sense que se'n pugui determinar l'adquirent). I el mateix es podria dir en aquells casos en què ni tan sols pot acreditar-se quan es va realitzar l'adquisició i el que es constata és només la possessió del bé pels cònjuges.

D'altra banda, la lletra de l'art. 49, par. 3r CDCC recordava, en aquest mateix punt, la redacció de l'art. 23 de la Llei 40/1960, de 21 de juliol, de la Compilació del dret civil especial de Catalunya (BOE núm. 175, de 22.7.1960). Aquest últim feia esment dels béns adquirits per la dona casada la procedència dels quals no podia justificar. L'art. 49 CDCC tractava, per la seva banda, dels "béns adquirits per un dels consorts durant el matrimoni l'adquisició del qual no es pugui justificar". A propòsit del primer, i atès el contrasentit que suposava exigir que s'acredités una adquisició per un dels cònjuges però que, alhora, no fos possible justificar-la, es va proposar interpretar "béns adquirits" per "béns posseïts" per la dona (PARA MARTÍN, 1981, p. 94). Una línia d'interpretació semblant es va seguir en el comentari a l'art. 21 CDCC (MIRAMBELL ABANCÓ, 1995, p. 195). En referència a l'art. 49 CDCC, la STSJ Catalunya, Secc. 1a, 19.10.1993 (RJ 1993\10181; *MP: Jesús Corbal Fernández*) destaca que aquella norma "presume el carácter privativo del dinero si consta que los bienes fueron adquiridos por un cónyuge, pero en absoluto presume la adquisición, ésta hay que probarla …".

Quant al dubte sobre la titularitat, vegeu la SAP Girona, Secc. 1a, 13.12.2006 (JUR 2007\143594; *MP: Fernando Ferrero Hidalgo*) i SAP Girona, Secc. 2a, 11.4.2005 (JUR 2005\123615; *MP: José Isidro Rey Huidobro*). En ambdues s'aclareix aquella incertesa atenent a les normes en matèria d'accessió. A la seva empara, s'acaba declarant la titularitat de la vivenda a favor de qui ja era, al seu torn, titular del sòl. Amb tot, a la primera d'elles, recaiguda en un procés de divorci, s'adverteix que la determinació de la titularitat de l'habitatge només es planteja en la mesura que és necessari a fi d'atribuir-ne l'ús (en concret, per saber a qui ha de correspondre en cas de no poder-se apreciar una especial necessitat de vivenda en un dels cònjuges).

A propòsit de l'onerositat de l'adquisició, s'entenia implícita a l'art. 49 CDCC; d'aquí la presumpció amb què concloïa la norma. Si escau, la prova del pagament i, en particular, de qui va pagar, pot espantar els dubtes sobre la titularitat del bé i evitar així l'aplicació de l'art. 232-4 CCCat (art. 386 LEC).

Davant el dubte, l'art. 232-4 CCCat reacciona establint dues regles: la general seria la d'entendre que els béns pertanyen a ambdós cònjuges a parts iguals indivises; l'especial, que regiria per raó del tipus de bé, seria la de declarar la titularitat exclusiva a favor del cònjuge usuari. De fet, ambdues regles fan ús d'un mateix mecanisme, així: el de fixació legal de la titularitat, que en cap cas admetria prova en contrari. Tota la que s'arribés a aportar a fi d'acreditar que el bé pertany només a un dels cònjuges o, en el cas previst a l'art. 232-4 *in fine* CCCat, a aquell que no l'utilitza, seria una prova encaminada, no tant a contradir el fet presumpte, sinó a desacreditar la concurrència del fet base.

Que no es tracta d'una presumpció ho confirmaria, almenys a propòsit de la regla general, que no s'arriba a veure l'enllaç lògic que hi ha d'haver entre el supòsit de fet (en especial, el dubte) i la

conseqüència (l'atribució de la titularitat a ambdós cònjuges en proindivís), propi de les presumpcions. Es diria que "no és el que acostuma a passar". Pel contrari, es tracta d'una norma de tancament que, prescindint de probabilitats, intenta almenys ser equitativa (vegeu, defensant que la regla especial es presenta com a presumpció iuris tantum, PUIG I FERRIOL [2000, p. 230,]; estenent aquesta mateixa configuració a la general, SOLÉ RESINA [2010, p. 231]).

D'altra banda, la regla especial parteix de la distinció entre dos grups de béns: el primer reuneix els d'una determinada naturalesa, ús i valor; en el segon, l'element comú és el destí. El primer s' integra pels béns mobles d'ús personal que no siguin d'extraordinari valor. L'ús personal exclouria el familiar (art. 232-3.2 CCCat) i el seu valor extraordinari (així com el "ordinari" a l'art. 232-3.2 CCCat), ha de valorar-se atenent al nivell de vida familiar (art. 231-10.2 CCCat) Remetent-se al valor objectiu del bé en el tràfic jurídic, prescindint del que pugui tenir en el patrimoni del cònjuge usuari, vegeu PUIG I FERRIOL (2000, p. 231). Quant als béns destinats a l'activitat d'un dels cònjuges, la norma ni exigeix el seu caràcter mobiliari ni concreta l'abast d'aquella activitat (art. 232-32 e CCCat). Si que demana que la destinació sigui "directa" que, literalment, no equival a destinació exclusiva. Amb tot, l'efecte de l'atribució legal de la titularitat a només un dels cònjuges justificaria l'exigència d'un ús efectiu i exclusiu en el desenvolupament de l'activitat. D'altra banda, fixada a l'empara de l'art. 232-4 CCCat la titularitat exclusiva d'un dels cònjuges sobre algun d'aquests béns, la procedència aliena de la contraprestació satisfeta no permetrà aplicar l'art. 232-3.1 CCCat als efectes de presumir realitzada una donació. Estrictament, no es donarà el fet base del que parteix la presumpció (així, l'adquisició onerosa per un dels cònjuges que, a més a més, "consti" com titular).

4. Taula de jurisprudència citada

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tribunal, Sala i Data	*Ar.*	*Magistrat Ponent*
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 10.5.1993	RJ 1993\6323	Jesús Corbal Fernández
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 19.10.1993	RJ 1993\10181	Jesús Corbal Fernández
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 28.12.1993	RJ 1993\10203	Luis María Díaz Valcárcel
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 31.1.1994	RJ 1994\4587	Jesús Corbal Fernández
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 5.3.1998	RJ 1998\10049	Lluís Puig i Ferriol
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 27.6.2002	RJ 2002\10438	Núria Bassols Muntada
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 28.11.2002	RJ 2002\10924	Guillermo Vidal Andreu
STSJ Catalunya, Secc. 1a, 07.6.2010	RJ 2010\3750	José Francisco Valls Gombau

Audiències Provincials

Tribunal, Sala i Data	*Ar.*	*Magistrat Ponent*
SAP Barcelona, Secc. 14a, 4.11.2003	JUR 2004\4484	Mª Eugenia Alegret Burgués
SAP Barcelona, Secc. 13a, 29.7.2004	JUR 2004\288508	Isabel Carriedo Mompín
SAP Girona, Secc. 2a, 11.4.2005	JUR 2005\123615	José Isidro Rey Huidobro
SAP Girona, Secc. 1a, 13.12.2006	JUR 2007\143594	Fernando Ferrero Hidalgo
SAP Barcelona, Secc. 17a, 28.5.2007	JUR 2007\295084	Amelia Mateo Marco
SAP Barcelona, Secc. 16a, 27.5.2010	JUR 2010\290654	Jordi Seguí Puntas

5. Bibliografia

Jaume AMETLLA CULÍ (2011), "Comentario al art. 231-12 CCCat", a Encarnación ROCA TRIAS (Coord.), *Persona y Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña,* Sepín, Madrid, pp. 578 i ss.

Lídia ARNAU RAVENTÓS (2006), *La declaración de concurso de persona casada y la composición de la masa activa. Estudio de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,* Atelier, Barcelona.

Ferran BADOSA COLL (1990), *Dret d'Obligacions*, Barcanova, Barcelona.

--- (2009), "El poder de disposició en el dret civil català. La constitució i la transmissió negocials dels drets reals", a Ferran BADOSA COLL i Mª Carmen GETE-ALONSO CALERA (Dirs.), *La adquisición y la transmisión de derechos reales. Estudio del derecho catalán y otros sistemas jurídicos*, Marcial Pons, Barcelona, pp. 33 i ss.

Joaquín BAYO DELGADO (2011), "Comentario al art. 232-3 CCCat", a Encarnación ROCA TRIAS (Coord.), *Persona y Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña,* Sepín, Madrid, pp. 687 i ss.

Esteve BOSCH CAPDEVILA (2008), "L'opció com a dret d'adquisició en el Dret civil de Catalunya", *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 4, pp. 975 i ss.

Anna CASANOVAS MUSSONS (1995), "Comentari a l'art. 18 CDCC", a Anna CASANOVAS MUSSONS, Joan EGEA I FERNÁNDEZ, Mª del Carmen GETE-ALONSO CALERA i Antoni MIRAMBELL I ABANCÓ (Coords.), *Comentari a la modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges,* Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 157 i ss.

Neus CORTADA CORTIJO (2011), "La protección de los acreedores de los cónyuges en el Derecho

civil de Cataluña: los artículos 231-11 y 231-12 del Código civil de Cataluña", a Reyes BARRADA ORELLANA, Martín GARRIDO MELERO i Sergio NASARRE AZNAR (Coords.), *El Nuevo Derecho de la Persona y de la Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña*, Bosch, Barcelona, pp. 219 i ss.

Pere DEL POZO CARRASCOSA, Antoni VAQUER ALOY i Esteve BOSCH CAPDEVILA (2008), *Derecho civil de Cataluña. Derechos reales*, Marcial Pons, Barcelona.

José GARBERÍ LLOBREGAT (2001), *Los procesos civiles. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, con formularios y jurisprudencia*, T. III, 1a ed., Bosch, Barcelona.

Mª del Carmen GETE-ALONSO CALERA (1996), "La compensación económica derivada de la liquidación del régimen de separación (art. 23 CDCC)", *La Llei de Catalunya i Balears*, núm. 2, pp. 625 i ss.

Fernando GÓMEZ POMAR (2000), "Comentari a l'art. 8 CF", a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA (Dirs.), *Comentaris al Codi de Família, a la Llei d'Unions estables de parella i a la llei de situacions convivencials d'ajuda mútua,* Tecnos, Madrid, pp. 119 i ss.

Joan MARSAL GUILLAMET (2000), "Comentari a l'art. 68 CF", a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA (Dirs.), *Comentaris al Codi de Família, a la Llei d'Unions estables de parella i a la llei de situacions convivencials d'ajuda mútua,* Tecnos, Madrid, pp. 336 i ss.

Antoni MIRAMBELL ABANCÓ (1995), "Comentari a l'art. 21 CDCC", a Anna CASANOVAS MUSSONS, Joan EGEA I FERNÁNDEZ, Mª del Carmen GETE-ALONSO CALERA i Antoni MIRAMBELL I ABANCÓ (Coords.), *Comentari a la modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges,* Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 188 i ss.

--- (2003), "El matrimoni i els seus efectes", a Ferran BADOSA COLL (Dir.), *Manual de Dret civil català*, Marcial Pons, Barcelona, pp. 454 i ss.

Antonio MONSERRAT VALERO (2010), "Los derechos voluntarios de adquisición en el derecho civil de Cataluña: clases y funcionamiento", *Anuario de Derecho civil*, T. LXIII, fascicle III, pp. 1125 i ss.

Susana NAVAS NAVARRO (1994), "Comentario al nuevo art. 21 CDCC", *La Llei de Catalunya i Balears*, núm. 72, pp. 1-4.

Pascual ORTUÑO MUÑOZ (2000), "Comentari a l'art. 41 CF", a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA (Dirs.), *Comentaris al Codi de Família, a la Llei d'Unions estables de parella i a la llei de situacions convivencials d'ajuda mútua,* Tecnos, Madrid, pp. 231 i ss.

Antonio PARA MARTÍN (1981), *Presunción muciana y nulidad de donaciones entre cónyuges en Cataluña*, Bosch, Barcelona.

--- (1999), "El derecho de compensación económica por razón del trabajo", *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 2, pp. 321 i ss.

Lluís PUIG I FERRIOL (2000), "Comentari a l'art. 39 CF", a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA (Dirs.), *Comentaris al Codi de Família, a la Llei d'Unions estables de parella i a la llei de situacions convivencials d'ajuda mútua,* Tecnos, Madrid, pp. 218 i ss.

--- (2000), "Comentario al art. 40 CF", a Joan EGEA I FERNÁNDEZ i Josep FERRER RIBA (Dirs.), *Comentaris al Codi de Família, a la Llei d'Unions estables de parella i a la llei de situacions convivencials d'ajuda mútua,* Tecnos, Madrid, pp. 225 i ss.

--- (2011), "Régimen jurídico de la contratación entre cónyuges en el Derecho civil catalán", a Reyes BARRADA ORELLANA, Martín GARRIDO MELERO i Sergio NASARRE AZNAR (Coords.), *El Nuevo Derecho de la Persona y de la Familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña,* Bosch, Barcelona, pp. 199 i ss.

Encarnación ROCA TRIAS (2008), "La liquidació del règim de separació de béns a Catalunya", *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 3, pp. 8 i ss.

Judith SOLÉ RESINA (2010), "El régimen económico matrimonial de separación de bienes", a Mª del Carmen GETE-ALONSO CALERA, Maria YSÀS SOLANES i Judith SOLÉ RESINA, *Derecho de familia vigente en Cataluña*, Tirant lo Blanc, València, pp. 186 i ss.

Antoni VAQUER ALOY (1999), "Inoponibilidad y acción pauliana (la protección de los acreedores del donante en el artículo 340.3 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña", *Anuario de Derecho civil,* Vol. 52, núm. 4, pp. 1491 i ss.

Francisco VIRGILI SORRIBES (1962), "El régimen legal de separación de bienes en la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña", *Anuario de Derecho civil,* Vol. 15, núm. 1, pp. 42 i ss.